



**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC**

DE LA CONCUSIÓN/ LEY 599 DE 2000

El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años¹.

CODIGO DISCIPLINARIO UNICO-Exigencias en deberes del servidor público en el servicio y en el trato no vulneran los principios de tipicidad, legalidad y debido proceso disciplinario

Los numerales 2 y 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, consagran para todos los servidores públicos: un deber general afirmativo relativo al cumplimiento del servicio que le haya sido encomendado con las exigencias de diligencia, eficiencia e imparcialidad; un deber general negativo referido a la abstención de cualquier clase de acto u omisión que origine la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial o el abuso indebido del cargo o de las funciones encomendadas, y una obligación de carácter general de comportarse con respeto, imparcialidad y rectitud en las relaciones interpersonales por razón del servicio público que le haya sido encomendado, deberes y obligaciones que constituyen un desarrollo de las normas constitucionales que son el fundamento de la responsabilidad disciplinaria, sobre los que la Corte encuentra que las expresiones demandadas son fiel desarrollo de mandatos constitucionales y son deberes y obligaciones generales y básicos que están consagrados en la Carta Política o constituyen un desarrollo de postulados de la administración pública y de la responsabilidad disciplinaria; que se encuentran en plena armonía con las finalidades constitucionales propias del derecho disciplinario; que no vulneran en sentido alguno los principios de tipicidad y legalidad rectores del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 Superior, y que no es cierto que estas expresiones constituyan tipos en blanco o conceptos jurídicos indeterminados respecto de los cuales el operador disciplinario no pueda llevar a cabo una remisión normativa o realizar una interpretación sistemática².

FALTA GRAVISIMA EN PROCESO DISCIPLINARIO-Realización de conducta descrita como delito/**FALTA GRAVISIMA EN PROCESO DISCIPLINARIO**-No condicionamiento a trámite de proceso penal

Para la demandante la aplicación del numeral 1º del artículo 48 de la ley 734 de 2002, requiere la participación de una autoridad judicial quien calificaría si la conducta por la cual se ha iniciado el proceso corresponde a un delito. Esta forma de interpretar el precepto demandado no corresponde a lo establecido por el legislador, pues en él quedó previsto que se consideran faltas gravísimas aquellas que atiendan a los siguientes supuestos: i) Que se trate de una conducta objetivamente descrita por la ley como delito; ii) Que la misma conducta punible sea sancionable a título de dolo; y iii) Que la misma conducta se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo. Para la Sala es evidente que el Congreso de la República no condicionó la aplicación de la norma sub examine al trámite de un proceso penal y menos aún a la calificación que una autoridad judicial hiciera respecto del comportamiento causante del proceso disciplinario. La disposición atacada obliga al “juez disciplinario” a verificar en la legislación penal si la conducta que ha dado lugar al proceso está descrita objetivamente o tipificada, para posteriormente establecer dentro del proceso a su cargo si la misma conducta fue cometida con dolo o culpa, con el propósito de imponer la respectiva sanción atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 734 de 2002 -Código Disciplinario Único-³.

¹ Artículo 404.

² Sentencia C – 030 de 2012.

³ Sentencia C – 720 de 2006.



POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-205

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número del Proceso:	1704-01-2013-205
Número y fecha del fallo:	RESOLUCIÓN No. 17317-00008 06 de abril de 2017
Asunto:	Fallo de primera instancia
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio de primera instancia

RESOLUCIÓN No. 17317-00008 06 de abril de 2017

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-205

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario 1704-01-2013-205, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

IDENTIDAD DEL INVESTIGADO

XXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número XXXXX, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como funcionario de planta de la Coordinación de Sustanciación de la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, en el cargo de Analista I, Código 201, Grado 01. (certificación que obra a folios 92 a 93).

Salario devengado por el funcionario para el año 2013 (Folios 97 y 98), comunicación de funciones correspondiente del mismo año (folios 94 a 96) y, por último, se tiene Certificado de Antecedentes Disciplinarios que figura a folio 147 que denota que del encartado no figuran sanciones ni inhabilidades vigentes.

HECHOS

Los hechos objeto de actuación tienen su génesis en el correo electrónico de fecha 10 de julio de 2013 remitido de la dirección electrónica XXXXX a la Doctora XXXXX, Subdirectora de Gestión de Registro Aduanero, a nombre de XXXXX (folio 6), mediante el cual se puso en conocimiento de la funcionaria que a principios del año 2013, el señor XXXXX (funcionario adscrito a dicha Subdirección), tramitó un registro aduanero a nombre de su cliente XXXXX identificado con C.C XXXXX, el cual les fue entregado para abril de 2013. Notaron al momento de solicitar la licencia de importación correspondiente, que había un error en un dígito de la subpartida arancelaria sobre una maquina topadora de oruga.

Una vez advertida la imprecisión se dirigieron donde el funcionario XXXXX quien, "en principio nos puso trabas para darnos la nueva resolución" refiriéndose al acto que corregía el error; aseguró el denunciante que días después el funcionario les dijo que el "trabajo" valía \$ 3.000.000,00.

Dos meses y medio después manifiesta, que lo empieza a llamar y su teléfono entra a buzón de voz, le deja varios mensajes de voz y de texto sin recibir una respuesta, al igual que correos electrónicos, lo que lo llevó a pensar que la demora habría sido generada por no haber pagado la presunta "extorsión".

Acompañan la noticia electrónica dos presuntos correos electrónicos en impreso, remitidos por la dirección de correo electrónico XXXXX, a la dirección XXXXX los días 16 de abril y 8 de mayo de 2013, en los cuales se observa un número de cédula y una cuenta del banco de Bogotá

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-205

respectivamente, de lo que afirma el denunciante son los que el funcionario ofreció para la consignación de la supuesta dádiva.

La presente noticia fue allegada para conocimiento de esta Agencia por la funcionaria XXXXX, quien remitió la noticia disciplinaria junto con algunos documentos de interés del proceso aduanero, lo cual hizo efectivo mediante oficio 100210228-442 del 12 de julio de 2013; (denuncia más anexos remitidos por la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero folios 2 al 74).

CARGO FORMULADO

En razón a las pruebas recaudadas durante la instrucción del plenario, la conducta por la que se llamó a responder al disciplinado en decisión 17406-00019 del 22 de agosto de 2016 es la siguiente:

CARGO UNICO: El señor XXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.522.874, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como funcionario de planta de la Coordinación de Sustanciación de la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, en el cargo de Analista I, Código 201, Grado 01, al parecer, incurrió en la conducta descrita en la Ley 734 de 2002, artículo 48 numeral 1°, en armonía con el artículo 404 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) conducta típica de concusión, en cuanto al parecer el día 30 de mayo de 2013, sobre el medio día, a las afueras de las instalaciones donde labora, abusó de su cargo como servidor público, al presuntamente realizar una solicitud indebida de dinero por un monto de TRES MILLONES de pesos (\$3.000.000) al señor XXXXX, representante legal del importador XXXXX, con el objeto de agilizar el trámite de una acto administrativo que corrigiera un error encontrado en la Resolución no. 002943 del 12 de abril de 2013 y culminar así el trámite de importación de una maquinaria.

ARGUMENTOS DE DEFENSA:**VERSIÓN LIBRE, DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Dentro de la actuación se efectuaron diversas intervenciones defensivas que a continuación serán debidamente detalladas:

Versión libre

En diligencia del 15 de enero de 2014, el disciplinado adujo las siguientes manifestaciones defensivas respecto de los hechos objeto de denuncia; manifestó encontrarse extrañado de los correos electrónicos en los cuales aparece su número de cédula y cuenta bancaria, pues el usuario no tenía motivos para tener esa información y adicionalmente manifiesta que la hora en que fue enviado el correo contentivo de su cuenta, no fue enviado en horas laborales, advierte que inclusive para la fecha de estos correos el solicitante ni siquiera se había notificado de la resolución.

Relató que de trato si conocía al señor XXXXX ya que vía telefónica se comunicaron para lo relativo al trámite de la resolución, pero niega haber concretado una cita con el mismo.

Respecto de las aseveraciones del señor XXXXX aduce que son parcializadas como quiera que es su apoderado el denunciante, adicionado al hecho de que en un aparte de su declaración el señor XXXXX reconoce no conocer de trato ni de vista al señor XXXXX.

Concluye manifestando que desde el 22 de junio al 9 de julio de 2013, se encontraba en período de disfrute de vacaciones y que junto al acta de entrega de puesto, uno de los ítems que debía dejar listo al jefe de sustanciación era el proyecto de corrección de la resolución de modificación del señor XXXXX en razón a que para salir al disfrute de sus vacaciones debía dejar su puesto al día, pero que se dejó sin firma pues dependían de un recurso que habían interpuesto.(Folios 123 a 129).

Memorial presentado por la defensa del 4 de noviembre de 2014

La defensa radicó memorial en el cual manifestó su ánimo de ampliar la versión rendida por su defendido el pasado 15 de enero de 2014 de la siguiente manera:

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-205

Se plantea el argumento de que la cronología de los hechos no parece tener coherencia con la adecuación típica pues el primero de los correos remitidos por su defendido (16 de abril de 2013) en el que se envió la cuenta bancaria del señor XXXXX, habría sido generado 7 días antes de la notificación personal de la resolución que le reconocía la calidad de importador al señor XXXXX, y respecto al del 8 de mayo del mismo año, en el que envía su cedula, 12 días después de la radicación de la solicitud de corrección de la autorización de importación tratando de alegar que no tendría sentido remitir dicha información al denunciante si aún no se conocía del error en el que estaba inmerso el escrito. Al respecto la defensa manifestó: "No se encuentra motivo aparente para haberle enviado del correo institucional este tipo de información al usuario, máxime cuando aún no se producían las situaciones objeto de la presunta situación objeto de investigación (fechas indicadas en el punto noveno de los hechos). Sin embargo, podría decir en beneficio del disciplinable, que según su decir otras veces ha utilizado ese medio con compañeros de la entidad para cuestiones personales, tal vez por error involuntario pudo haberlo enviado al usuario." (folio 253).

También se alegó que el día 21 de junio de 2013, previo a su retiro a vacaciones el funcionario suscribió acta de entrega de expedientes a cargo, dentro de lo cual hace entrega del proyecto de resolución de modificación, adiciona que el proyecto de acto administrativo se hizo atendiendo las indicaciones escritas de la Subdirectora, por lo que las funciones del señor XXXXX fueron únicamente técnicas.

Igualmente, manifiesta que el despacho debe tener en cuenta que muchos de los sucesos que retardaron la expedición del trámite fueron acaecidos durante la ausencia de su cliente por vacaciones, como la resolución del recurso y el envío a la seccional de Medellín por error de este acto administrativo, tal y como se encuentra explicado en el numeral séptimo de la resolución no. 6847 del 12 de agosto de 2013.

Alegatos de conclusión

Mediante memorial allegado de manera electrónica el pasado 3 de marzo de la presente anualidad, el abogado de la defensa, remite memorial de alegatos finales, en los cuales expone de manera definitiva las argumentaciones conclusivas a saber.

Aduce la defensa que la conducta endilgada por este despacho en decisión de cargos no. 17406-00019 del 22 de agosto de 2016, se encuentra cobijada por atipicidad objetiva lo cual fundamenta en varias de las pruebas acopiadas por el despacho.

Señalo respecto del testimonio de la señora XXXXX, quien se desempeñaba como jefa directa del encartado, para el período en que sucedieron los hechos que aquí se examina, que del mismo se extrajo que el funcionario fue asignado al grupo de maquinaria amarilla directamente por la Subdirectora de Gestión de Registro Aduanero para el mes de febrero o marzo, pues era un tema prácticamente nuevo y el decreto reglamentario sobre el tema salió tres meses después de autorizado el trámite razón por la cual los trámites elevados para febrero de 2013 sufrían demoras.

Puntualizó que la funcionaria refirió una serie de controles tanto para el reparto como para la firma de las resoluciones tramitadas las cuales eran detalladamente revisadas, y para concretar esta situación trajo a colación el caso en particular de señor XXXXX a quien se le profirió un requerimiento de información por no cumplir con uno de los requisitos del importador en el formulario RUT lo cual fue revisado por XXXXX controlador del tema de maquinaria.

Por último, de este testimonio rescató que se mencionó que, para finales de mayo y principios de junio de 2013, sostuvieron un almuerzo con el señor XXXXX conocido de hace más de 15 años que había venido a la ciudad de Bogotá resaltando que una vez finaliza el almuerzo y despiden al viejo conocido se dirigen juntos a las instalaciones de la DIAN.

Para completar la idea manifiesta que el señor XXXXX concuerda con el testimonio de la señora XXXXX y recuerda de igual forma el susodicho almuerzo efectuado el 30 de mayo de 2013 del que apporto prueba bancaria documental, todas estas pruebas palmarias de que el día en que sucedieron los presuntos hechos su defendido se encontraba en compañía de su jefe inmediata y de su compañero en el establecimiento XXXXX, por lo que a todas luces las aseveraciones de quien dijo

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-205

llamarse XXXXX son tendenciosas y calumniadoras habida cuenta que una persona no puede encontrarse en dos lugares al mismo tiempo y a la misma hora, pero adicionalmente menciona que esta es la explicación para que las celdas de ambos abonados figuren en capitolio 3 y BOG senado K pues tanto la sede de la DIAN como el restaurante cubren dicho perímetro de ubicación y no porque se hubiesen encontrado para solicitar ningún tipo de cantidad de dinero pues dicha situación nunca sucedió.

Reitera que el presunto denunciante se negó a cumplir con los deberes legales que sin excepción le asisten de declarar o a lo sumo identificarse ante los funcionarios instructores, que en todo caso conllevaron a que el testigo no rindiera su declaración y se cerrara el período probatorio de esta manera por no encontrarse pendientes más pruebas por practicar, lo cual a su juicio no se compadece con la realidad procesal de la actuación.

Para la defensa constituye una irregularidad sustancial que afecta el debido proceso la renuencia y desobediencia constante del testigo estrella sin que se presentara evidencia de que estaba en peligro la seguridad del ciudadano, y por el contrario la instrucción no aplicó el principio de búsqueda de la verdad real y el principio de investigación integral haciendo conducir al testigo como lo faculta la ley.

Resalta que la documentación recibida al supuesto testigo en la ciudad de Barranquilla carece de validez al no cumplir con el lleno de requisitos legales para ser tenida en cuenta como pruebas al no ser introducidas dentro de una declaración juramentada, adicionalmente añade al descrédito de esta persona que se pudo corroborar que el mismo no tienen calidad de abogado del señor XXXXX si no tenía la calidad de un simple tramitador.

Por último, recalca que del testimonio del señor XXXXX se pudo conocer que el error provino de su causa y riesgo al presentar un error en la casilla 39 de la subpartida arancelaria y que si la petición sufrió percances se debió a la propia responsabilidad del peticionario quien solicitó la corrección debido a su impericia y no a una falla del servicio o del sustanciador mucho menos, esto y que el trámite para su corrección requiriera la dación de una coima en contraprestación cae de su peso para el defensor, pero más allá de lo anterior recalca el memorialista que el testigo precisó no constarle la cuestionada petición de dinero y que dicha información provenía de XXXXX lo que lo convierte en un testigo de oídas el cual al no tener conocimiento directo de los hechos no le representa la contundencia necesaria lo que lo conlleva a solicitar la absolución de su cliente al concluir la atipicidad de la conducta y la ausencia de responsabilidad del disciplinado.

6. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA:**RAZONES DE LA DECISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN QUE SE BASA****6.1. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA:**

Este Despacho es competente para proferir el fallo de primera instancia dentro de la presente investigación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con las previsiones del Decreto 4173 del 3 de noviembre de 2011.

En atención a lo ordenado en el Artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, cuya apreciación debe corresponder a las reglas de la sana crítica, según lo establece el Artículo 141 ibídem.

De igual manera, deben reunirse de manera conjunta los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, reglados en los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002, los cuales es menester se encuentren debidamente acreditados dentro del sumario a partir de elementos de prueba legalmente allegados al proceso.

La certeza corresponde a un estado mental de seguridad y, por lo tanto, de firme adhesión o asentimiento a la verdad de una proposición, fundada en una razón que excluye completamente y, por ende, libera del temor de la verdad de lo contrario. Certeza del hecho es la segura, firme, precisa

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-205

y clara convicción que el operador disciplinario tiene acerca de la ocurrencia de una falta disciplinaria. Certeza de la responsabilidad es el convencimiento que adquiere el operador disciplinario acerca de la comisión de una conducta por parte del destinatario de la ley disciplinaria, resultante del análisis crítico y juicioso de las pruebas obrantes en la investigación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizará el material probatorio obrante en el expediente para concluir si el disciplinado es o no responsable de la comisión de la falta disciplinaria prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, conforme a la imputación elevada en el auto de pliego de cargos.

6.2 DEL CASO EN CONCRETO**De la actuación procesal**

Mediante decisión del 18 de julio de 2013 No. 17403-145 se resolvió iniciar etapa de indagación preliminar con implicados por establecer (folios 75 y 76), a efectos de verificar los hechos objeto de denuncia, así como sus antecedentes y la plena identificación del presunto autor de los mismos, conforme lo descrito en el artículo 150 de la ley 734 de 2002.

Posteriormente y dados los hallazgos hasta el momento constituidos en etapa preliminar, el despacho mediante decisión no. 17417-541 del 22 de octubre de 2013 determinó vincular al señor XXXXX, quien fuera notificado de manera personal del presente proveído el 23 de octubre del mismo año, como consta en acta a folios 102 y 103. Con proveído del 25 de junio de 2014 no. 17404-058 se ordenó la apertura de investigación disciplinaria formal (folio 182 a 185) de lo cual se notificó el funcionario el día 21 de julio de 2014 (folio 195)

Con auto no. 17405-00020 del 24 de diciembre de 2015, se decretó la prórroga de la investigación con el fin de decretar unas pruebas que este despacho consideró en su momento necesarias, las cuales se practicaron en su totalidad, salvo la ampliación de la doctora XXXXX como quiera que al verificar el contenido de la diligencia que ya se surtió no resultó necesario, por lo que este despacho al decretarla de oficio decidió desistir de ella. (Folios 310).

El 28 de abril de 2016, se decretó el cierre de la investigación (auto no. 17410-00021) Folio 318; lo cual fue notificado de manera personal como consta en acta a folio 320 el día 6 de mayo de 2016.

Mediante proveído no. 17406-00019 del 22 de agosto de 2016 se produjo decisión de cargos en contra del señor XXXXX gallo (Folios 343 a 354), decisión que fuera notificada de manera personal como consta en acta a folio 357 el 25 de agosto de 2016. Con auto de trámite del 8 de septiembre de 2016 el despacho reconoció personería para actuar al doctor XXXXX en reemplazo de la doctora XXXXX (Folio 370).

Con proveído 17416-00021 del 10 de noviembre de 2016 el despacho resolvió las pruebas en descargos y nulidades que la defensa impetró en memorial obrante a folios (393 a 402); Por último, mediante auto interlocutorio 17416-00001 del 12 de enero de la presente anualidad se decretaron desiertos los recursos de reposición y apelación interpuestos por la defensa al encontrarse que fueron sustentados de manera extemporánea (Folios 453 a 455), y teniendo en cuenta lo anterior se dio traslado para alegar de conclusión con proveído 17421-00002. (Folio 458)

De las pruebas y su valoración

Conforme lo dispuesto en el artículo 170 de la ley 734 de 2002 el fallo debe ser motivado y contener entre otros aspectos el análisis de las pruebas en que se basa, y siendo este uno de los presupuestos a abastecer se hará una relación de las pruebas que permiten sustentar la presente decisión:

Documentales**actuación aduanera**

-El día 14 de febrero de 2013, el importador XXXXX, remite memorial junto con la documentación tendiente a que se le acredite como importador, incluyendo el formato no. 1786, su partida arancelaria 84.29.19.00.00 (Folios 15 a 21)-Resolución no. 2943 del 12 de abril de 2013 "por la cual se autoriza como importador de maquinaria y sus partes clasificables en la Subpartida 00 del Arancel

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-205

De Aduanas", a nombre de XXXXX proyectado por el señor XXXXX (Folios 70 a 74). Lo anterior le sería notificado al ciudadano el 24 de abril del mismo año como obra en acta a folio 74.

-Con Oficio dirigido a XXXXX Y XXXXX de fecha 26 de abril de 2013, el señor XXXXX solicita que se cambie la partida arancelaria, pues la misma presentaba un error en la casilla 39 en el número de clasificación, lo cual se acompaña de la copia del formulario 1786 donde se evidencia el error (Folios 4 y 5) (Folios 68 y 69)

-En misiva del 22 de julio de 2014 (Folio 200 a 211), la Subdirección de Registro Aduanero informó lo siguiente:

Verificación del sistema REGYSTRAR no. 1301 en el que se evidencia que el responsable de darle respuesta al requerimiento de XXXXX era el señor XXXXX, acto administrativo que rechaza el recurso de reposición de fecha 8 de julio de 2013 No. 1105, copia de la Resolución 6847 del 12 de agosto de 2013 "Por la cual se modifica la resolución 2943 del 12 de abril de 2013" y registro de entradas y salidas del señor XXXXX, de fecha 30 de mayo de 2013.

-Certificación emitida por la Coordinación de Tesorería de la Subdirección de Gestión de Recursos en la cual se reporta que la cuenta de nómina del señor XXXXX es la no. 033-434028 (Folio 99)

-La Jefatura de la Coordinación de Nómina certificó que el funcionario XXXXX disfrutó vacaciones del 24 de junio de 2013 al 15 de julio de 2013 (Folio 191)

-A folio 212 se remite certificación con los datos biográficos de las líneas celulares 3106306529 de propiedad de la señora XXXXX en la ciudad de Barranquilla, (Folios 213 y 214), 3114187117 a nombre de XXXXX también en la ciudad de Barranquilla (Folios 215 a 218) y por último la línea XXXXX a nombre de XXXXX Fondo de Empleados. (Folios 219 a 220).

-A folio 222 figura planilla de entrega de documentos evaluador, no. 395 de fecha 3 de mayo de 2013 en la cual se verifica que con no. de radicación 27570 del 29 de abril de 2013 se entregó corrección de resolución no. 2943 del 12 de abril de 2013, recibido por XXXXX.

-Acta de entrega del puesto de Trabajo por situación Administrativa de disfrute de vacaciones con fecha de entrega 21 de junio de 2013 en la cual respecto del expediente de XXXXX se hace entrega del informe SEGG con corte 21 de junio de 2013 (Folios 265 a 269)

-A folio 280 se cuenta con certificación emitida por la Cooperativa de empleados XXXXX, la cual certificó que el abonado 3124496552 pertenece al señor XXXXX.

-A folio 307 a 309 obra prueba de llamadas entrantes y salientes de los celulares XXXXX (de propiedad del señor XXXXX), y los abonados XXXXX y XXXXX aportados por el denunciante como los números de los cuales se comunicaba con el funcionario. Dicha prueba fue ejecutada a través de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación por tratarse de una búsqueda selectiva en bases de datos.

Correos electrónicos

- Correo fechado 12 de abril de 2013, remitido por XXXXX mediante el cual se le remitió al señor XXXXX códigos a de las resoluciones de autorización para los importadores entre ellos XXXXX (folio 67)

-Correo electrónico de 15 de julio de 2013, mediante el cual la funcionaria XXXXX le corrobora al señor XXXXX la recepción de los documentos enviados a ella el pasado 10 de julio, y se le informa que los ha enviado a la instancia pertinente. (Folio 10)

-Correo electrónico del 22 de julio de 2013 remitido por la doctora XXXXX en el cual le informa al importador XXXXX, como respuesta al estado de su solicitud que su proceso se encuentra en análisis y revisión y se le informa igualmente que la queja fue remitida a esta Agencia (Folios 78 y 79).

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-205

-Correo de fecha 1 de agosto del mismo año, en que la Subdirectora de Registro Aduanero le informa al señor XXXXX que para tomar la decisión de fondo respecto de la solicitud de corrección se estaba a la espera del Auto no. 001105 del 8 de julio de 2013 debidamente notificado, por medio del cual se rechazó el recurso de reposición, el cual se encontraba aún en poder de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, Coordinación de Notificaciones. (Folio 84)

-la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones remitió para que obrara como prueba dentro de esta actuación archivos tipo carpeta personal .pst, contentivas de la bandeja de correo institucional de la cuenta XXXXX de propiedad del señor XXXXX, dentro de lo cual se recopiló lo siguiente:

Correo fechado 27 de marzo de 2013 remitente XXXXX, para XXXXX en el que le envía en archivo adjunto el documento "Requerimiento único de Información" (folios 148 y 149)

Correo fechado 7 de abril de 2013 remitente XXXXX para XXXXX en el cual el abogado solicita se le informe el estado de la solicitud hecha por el señor XXXXX, cuyo requerimiento no. 100228345-1958 ya habría sido contestado. (Folio 150) dicha misiva habría sido reenviada el día 8 con copia a la señora XXXXX (folio 151).

A dicha misiva responde la dirección XXXXX el 10 de abril de 2013, en el que le informa al señor XXXXX lo siguiente "XXXXX estoy revisando la documentación radicada y observo que no se toma la molestia de copias, la manifestación de plasmarla en una hoja aparte y firmarla por el señor XXXXX, así si es posible realizar las cosas. Por favor me llama"

Correo del 16 de abril de 2013 remitido a las 05:08 pm, remitente XXXXX, para XXXXX con el mensaje "XXXXX. ESTE ES EL N° DE CUENTA XXXXX DEL BANCO DE BOGOTÁ CTA AHORROS" (Folio 153)

Correo del lunes 22 de abril de 2013 (08:55 am) de XXXXX para XXXXX, en el que expresa que el documento lo devolvieron y le pregunta si él sabe con quién puede ponerse en contacto (Folio 154)

Correo del lunes 22 de abril de 2013 (04:59 pm) de XXXXX para XXXXX, en el que este le pide ayuda para recuperar la resolución por cuanto debe hacer declaración anticipada (Folio 155), a este correo responde el señor XXXXX, que la resolución debía estar en poder de la Administración de Riohacha pues allá se envió y que se demoraría en devolverla a Bogotá. (Folio 156)

Correo del 30 de abril de 2013 de XXXXX para XXXXX, en el cual le remite en archivo anexo comunicación de asunto "Corrección Resolución no.002943/abril 12 de 2013" más formato 1786 corregido (Folios 158 a 160)

Correo del 6 de mayo de 2013 de XXXXX para XXXXX, en el cual le remite en archivo adjunto copia de la negación de la licencia por parte de la administración y le remite el siguiente mensaje "Le adjunto copia de la negación de la licencia, en ella encontrará las causales de la negación, espero su concepto "(Folios 161 a 164)

Correo del 8 de mayo de 2013 remitido a las 10:12 por XXXXX, para opegar@hotmail.com con el mensaje "79522874" (Folio 166)

Correo del 8 de mayo de 2013 remitido a las 11:25 por XXXXX dirigido al XXXXX con el archivo adjunto "apelación resolución XXXXX"(Folio 168)

A folio 175 figura conversación del señor XXXXX con la dirección XXXXX en la cual este remitente le comunica "Le estoy enviando el recibido de la DIAN, ELLOS LO ENVIARON PARA Bogotá para que se haga la corepción (SIC) correspondiente, llame al señor que nos ayudó en Bogotá para que le colabore"lo cual a su vez Oscar Pérez reenvía a XXXXX, el día 9 de mayo con el mensaje "Te estoy llamando esta tarde" (Folio 175 a 176)

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-205

Correos del 9 de julio de 2013 de las 10.22 am del señor XXXXX a XXXXX, en el que le informa que lo ha estado llamando y no contesta y que espera respuesta cuanto antes (Folio 178), y uno siguiente de la misma fecha de las 2:15 de la tarde en el que le manifiesta que se encuentra a la espera de respuesta (Folio 179)

Por último, correo electrónico del 17 de julio de 2013 dirigido por XXXXX en el cual le manifiesta que recibe con extrañeza sus amenazas de hablar con la Directora, pues le comenta que se ausentó por vacaciones y la resolución la dejó proyectada (Folio 180)

1. Testimonios

XXXXX: rindió su declaración el pasado 25 de septiembre de 2013 (Folios 100 y 101). Manifestó ser de profesión ganadero; recordó que realizó trámites ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para importar un bull dozer pero aseveró que hizo todas las gestiones a través de XXXXX, aproximadamente a principios de febrero de 2013.

Al serle preguntados los hechos origen de actuación, acotó recordar que el señor XXXXX le comentó que durante la ejecución del trámite en efecto hubo una dificultad en la resolución por el error en un dígito y que el encargado del trámite "un señor XXXXX" les estaba pidiendo 5 millones para realizar la corrección y que luego bajo la suma a 3.

Al serle preguntado por la entrega del dinero al funcionario manifestó que no se había hecho empero conocía que el funcionario de la DIAN le había hecho llegar al abogado su número de cuenta y cedula de ciudadanía para que le hiciera la consignación o giro del dinero solicitado. Concluyó manifestando que no ha tenido ningún contacto directo con el señor XXXXX.

XXXXX: rindió su declaración el 12 de noviembre de 2013 (Folios 106 a 107). Jefa directa del procesado dentro de la Subdirección de Registro Aduanero. Manifestó que conoció de los hechos vía correo electrónico remitido por el señor XXXXX de fecha 10 de julio de 2013 y de inmediato lo puso en conocimiento de esta Agencia. Tras relatar de manera concisa el trámite surtido, culminó manifestando que finalmente mediante Resolución no. 006847 del 12 de agosto de 2013 se modificó la resolución no. 002943 del 12 de abril de 2013, en el sentido de reemplazar la subpartida que contenía el dígito erróneo.

Adujo que en efecto el señor XXXXX tenía a su cargo dicho expediente, y al preguntarle este despacho si había notado alguna demora inusitada en su trámite manifestó:

Lo que recuerdo es que el señor XXXXX estuvo de vacaciones durante el período Junio-Julio de 2013, sin embargo, al revisar el expediente, observo que la solicitud inicial fue presentada el 06 de febrero de 2013, las deudas fueron solicitadas el 18 de febrero de 2013, el requerimiento de información efectuado al señor fue realizado el 12 de marzo de 2013, la respuesta al requerimiento la dio el señor 01 de Abril de 2013, y la resolución de Autorización 2943 se expidió el 12 de Abril de 2013. El 09 de mayo el señor XXXXX, apeló la resolución No. 2943 de 12 de abril de 2013 y el 08 de julio de 2013 con el Auto 1105 se rechazó el recurso interpuesto. Posteriormente ante la solicitud de corrección a la Resolución no. 2943 del 12 de abril de 2013 efectuada por el señor XXXXX se expidió la Resolución 6847 del 12 de agosto de 2013 y ejecutoriada el 6 de septiembre de 2013. (folio 107)

Finalizó manifestando que desconocía de otras quejas que hubiera del funcionario y que en su opinión general él siempre estaba pendiente de que sus actos administrativos salieran dentro del término legal.

PRUEBAS EN DESCARGOS

Las pruebas solicitadas por la defensa y que habrían sido decretadas por considerarse pertinentes y conducentes son:

XXXXX: Jefe de la Coordinación de Sustanciación para la época, manifestó que el señor XXXXX fue asignado al grupo de maquinaria amarilla para marzo o febrero de 2013, debido a que reconoce que

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-205

el grupo y el decreto reglamentario del tema era reciente existía un represamiento evidente de solicitudes.

No recordó en concreto la solicitud en particular, pero respecto del procedimiento en general comentó que una vez hecho el reparto está sometido a revisión de un controlador específico para cada tema y a su vez al jefe de sustanciación y por ultimo al despacho de la subdirectora.

Se clarificó de igual forma que antes de una situación administrativa se hacía una reunión y verificación de trámites pendientes con el controlador y el funcionario, y es así como se introduce la correspondiente acta de entrega del funcionario disciplinado tras su salida a vacaciones para el periodo de julio de 2013.

Por último, manifestó que, a finales de mayo, principios de junio fueron a almorzar en un restaurante cercano a la oficina con el señor XXXXX un excompañero que se encontraba en la ciudad, almuerzo al que fue convidado el señor XXXXX y que tuvo lugar en un lugar cercano a la oficina de nombre "Patagonia", del que una vez culminaron retornaron juntos al edificio XXXXX. (Folios 437 a 439).

Ampliación XXXXX: Recordó conocer al señor XXXXX a través^ de un mecánico porque tenía conocimiento y le podía ayudar en la compra de una maquinaria y fue quien gestionó los trámites, aseveró nunca haber dicho que el señor XXXXX era abogado, ni le confirió poder para actuar en su representación y le reconoció una comisión por los trámites en Estados Unidos. Recalcó tratarse de una especie de tramitador quien tenía conocimiento de lo procedente ante la DIAN.

Fue tajante en aseverar que nunca se adujo que él era abogado ni similares y que desconocía su documento de identidad, lugar de residencia o las razones para no comparecer a declarar a la actuación presente, añadió que creía que el mismo no se encontraba en el país. Finaliza su intervención manifestando que no le consta la presunta petición de dinero, n conoce ni se comunicó nunca con el funcionario vinculado y que desconoce de igual forma si hubo entrega de dinero alguno. (folios 441 a 444)

XXXXX: ex compañero de la DIAN quien recordó que el día 30 de mayo de 2013 se encontró con la señora XXXXX y XXXXX en cercanías al edificio XXXXX para invitarlos a almorzar, aportó como muestra de dicho suceso copia del extracto de su tarjeta de crédito que acreditaría que estuvieron en el restaurante XXXXX. (499 a 452).

Verificación de la identidad del señor XXXXX: Como se puede verificar en el expediente durante las etapas del procedimiento ordinario se intentaron desplegar las gestiones tendientes a establecer la plena identificación del denunciante a saber; el día 1 de agosto de 2013, los funcionarios abogados adscritos a esta Subdirección XXXXX Y XXXXX, contactaron al señor XXXXX, quien ubicado en la ciudad de Barranquilla adujo negarse a rendir declaración bajo la gravedad de juramento por temor de su integridad personal y de su familia, en dicha oportunidad allegó escrito sin firma del cual hizo entrega a los funcionarios de esta Subdirección en el Centro Comercial Buena Vista (Folios 88 a 90).

El 3 de octubre de 2014, el funcionario comisionado XXXXX procedió a tratar de ubicar al señor XXXXX, a través de la dirección obtenida de los datos biográficos allegados por la empresa XXXXX referente a las líneas telefónicas ofrecidas por el señor XXXXX en su denuncia; sin embargo, al llegar al lugar reportado ubicado en la carrera XXXXX, le manifestaron que XXXXX no laboraba allí pero si uno de sus familiares, le suministraron el abonado telefónico XXXXX. Tras intentar comunicarse a este, así como a los abonados aportados en la queja no fue posible lograr contacto con el señor XXXXX. (folios 270 a 274)

El 12 de septiembre de 2016 se le remitió nueva citación para comparecer a rendir testimonio (Folios 375 y 376) correo que habría sido contestado el mismo día a través de una llamada del abonado XXXXX cuyo interlocutor era el señor XXXXX indicando que recibió la citación hecha, pero que no asistiría y que se encontraba en la ciudad de Tampa (Folio 378). El Consejo Superior de la Judicatura certificó que en sus registros no figura ningún registro a nombre de XXXXX con los datos suministrados (Folio 391).

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-205

Por último, el 30 de noviembre de 2016 (Folio 392) se le envió una nueva misiva, intentando acordar nueva fecha y hora, a lo que se dio respuesta inmediata por correo electrónico indicando "no sé de qué me habla, hasta ahora no tengo problemas con nadie". El 18 de noviembre de 2016 la Dirección Nacional de Identificación informó que no era posible ofrecer información específica respecto de la identificación de la persona llamada XXXXX pues en las bases de datos de dicho ente figuran una serie de anónimos. (Folio 462)

Una vez culminada la fase probatoria en descargos, coincide la instancia de conocimiento en que varias de las situaciones denotadas en el escrito objeto de denuncia guardan correspondencia probatoria exacta con los hechos, como lo es por ejemplo la asignación del trámite en cuestión al funcionario vinculado, la traza del trámite surtido y el objeto de la actuación aduanera correspondiente a la importación de una maquinaria que sufrió un percance a causa del error en un dígito de la subpartida arancelaria, error atribuible a la parte solicitante.

De la situación descrita de manera lacónica en renglón anterior, es necesario hacer apreciaciones específicas que se develaron dentro del devenir de la etapa subsiguiente al escrito de cargos. Conocidas las circunstancias que enmarcan los hechos, para este despacho hasta este momento no resulta clara la identidad del señor XXXXX ni su papel frente a las gestiones que desempeñó para XXXXX en su calidad de importador. Si bien y aunque no lo comparte el defensor, este despacho realizó cada una de las actividades que estuvo a su alcance para lograr la ratificación del denunciante agotando cada acto posible de ubicación, pues se es consciente de la necesidad de la ratificación y de la contradicción y el ejercicio de la debida defensa, pero que a la postre no fue posible ubicar, identificar ni lograr que el presunto denunciante aportara bajo la gravedad de juramento la prueba testimonial requerida para el curso de la actuación.

Si bien la tarifa legal no es principio de la dirección probatoria procesal de la actuación administrativa sancionatoria, es claro que en este caso en particular resultaba necesario establecer y precisar bajo la gravedad de juramento varias de las situaciones fácticas que hoy en día resultan serios indicios en contra del señor XXXXX. La investigación integral y la búsqueda de la verdad real y no simplemente material, resultan estandartes de la administración de justicia, lo que a todas luces compele al operador disciplinario a establecer más allá de toda duda razonable la responsabilidad en cabeza de los funcionarios autores de conductas reprochables.

Para el caso en particular, deberá aplicarse el principio de in dubio pro disciplinado, teniendo en cuenta que subsistió una duda innegable que favorece al vinculado y del caudal probatorio allegado en total dentro de todo el curso del proceso no permite que se mantenga la imputación en sede de fallo por cuanto los elementos arribados en traslado de descargos, generan serias dudas que atentan contra la firmeza de la acusación y conminan al fallador a dar aplicación directa al artículo 9 de la Ley 734 de 2002, que recoge el principio jurisprudencial del in dubio pro disciplinado de la siguiente manera:

"(...) Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla"

Como se manifestó anteriormente, genera duda a este despacho adicional a la falta de ratificación del quejoso sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar de la entrega del dinero, -acción materializadora del verbo rector de la imputación-, el hecho de que tanto los testigos XXXXX como XXXXX refieran una situación acaecida el 30 de mayo de 2013 a medio día relativa a un almuerzo surtido en cercanías a la DIAN y que aducen los testigos tuvo lugar en el espacio del medio día, situación que hace mella en la firmeza del cargo elevado y en supuesto dicho del ahora denunciante, pues los testigos coinciden en aseverar que el funcionario retornó a la entidad en conjunto con su jefe directa para ese momento.

El relato ofrecido por los testigos fue coherente y coincidente entre sí, y uno de ellos aportó prueba documental que amerita credibilidad por parte de este despacho sin que exista un motivo determinante para predicar su tacha de falsedad.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-205

Adicionado a lo anterior dentro del caudal probatorio existe un único testigo de referencia quien no aportó mayores elementos de juicio que permitan ratificar la acusación, máxime teniendo en cuenta las características del testimonio que ofreció, el cual no puede ser valorado con el mismo grado de certeza que un testigo directo de los hechos.

La conducta tipificada como concusión, tiene la particularidad de que en materia probatoria no concurre en un número ilimitado de medios que puedan acompañarle sino por el contrario, de manera general, únicamente se tiene el testimonio del sujeto ofendido, el cual requiere un examen exigente y riguroso por parte del fallador pues si bien no existe tarifa legal, por ser la prueba por excelencia de este tipo de conductas merece un estudio muy estricto, que como ya se mencionó no puede hacerse dicho examen pues el denunciante no compareció a cumplir con su deber.

Al verificar los diferentes componente modales y circunstanciales que rodearon la presunta conducta desplegada por el señor XXXXX en su calidad de Analista I de la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, se tiene que no fue posible establecer los ítems de tiempo, modo y lugar de manera fehaciente, pero que además al analizar la trazabilidad del trámite de registro efectuado por el funcionario acusado este no sufrió demora o gestión deficiente alguna intencional, o que denotara alguna maniobra del funcionario para favorecer al usuario aduanero sino por el contrario no se observaron mayores novedades en la ejecución del mismo, esto adicionado al testimonio de su jefe directa y al del coordinador del grupo de sustanciación al que pertenecía el implicado quienes indicaron que el trámite paso por diversos controles que incluían el funcionario controlador delegado para el caso, el jefe de la coordinación de sustanciación y por último la Subdirectora; debe sumarse una circunstancia desconocida para este despacho hasta el momento de la acusación y es que el grupo para maquinaria amarilla así como la reglamentación de importación para estos casos era reciente para la época de los hechos por eso hubo demoras en el trámite de este tipo de solicitudes, aspecto que podría decirse favorece la premisa de duda sobre el actuar del funcionario.

Es entonces como no quedan claras las circunstancias en que se dio el contacto entre el funcionario y el señor XXXXX, en qué consistió la conversación y el número de veces que se contactaron, así como tampoco la manera en que se concretaría la presunta petición de dinero; y en definitiva se aplicara este precepto a la calificación de fondo de dentro de la referida actuación, esto porque no ha sido posible explicar por parte del funcionario a que obedecieron varios de los correos que hoy nos convocan, en especial el envío de la cuenta de nómina del funcionario resulta un indicio grave en contra del implicado que hasta este momento no ha sido desvirtuado, así como también causan serias dudas las llamadas entrantes y salientes en especial la del 30 de mayo de 2013, por lo que no puede predicarse en este punto la absolución por inocencia.

Al respecto se observa según el precitado artículo 09 del Código Disciplinario Único, que en virtud de lo dispuesto en su inciso segundo, al interior de la actuación disciplinaria, toda duda razonable ha de ser resuelta a favor del investigado siempre y cuando no exista modo alguno de eliminarla; dicha disposición es la consagración legal del principio de in dubio pro disciplinado, que puede entenderse como una derivación de la presunción de inocencia a que hace referencia el mismo artículo; dicha institución se sustenta en los presupuestos del artículo 29 Superior que consagra la garantía del debido proceso no solo en materia penal sino también al interior de un procedimiento como el que aquí se adelanta, en tal sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional en sentencia C-244 de 1996:

"El derecho fundamental que tiene toda persona a que se presuma su inocencia, mientras no haya sido declarada responsable, se encuentra consagrado en nuestro Ordenamiento constitucional en el artículo 29, en estos términos: "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable", lo que significa que nadie puede ser culpado de un hecho hasta tanto su culpabilidad no haya sido plenamente demostrada.

"El derecho fundamental que tiene toda persona a que se presuma su inocencia, mientras no haya sido declarada responsable, se encuentra consagrado en nuestro Ordenamiento constitucional en el artículo 29, en estos términos: "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable", lo que significa que nadie puede ser culpado de un hecho hasta tanto su culpabilidad no haya sido plenamente demostrada.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-205

Este principio tiene aplicación no sólo en el enjuiciamiento de conductas delictivas, sino también en todo el ordenamiento sancionador -disciplinario, administrativo, contravencional, etc.-, y debe ser respetado por todas las autoridades a quienes compete ejercitar la potestad punitiva del Estado.

Ahora bien: el principio general de derecho denominado "in dubio pro reo" de amplia utilización en materia delictiva, y que se venía aplicando en el proceso disciplinario por analogía, llevó al legislador a consagrar en la disposición que hoy se acusa, el in dubio pro disciplinado, según el cual, toda duda que se presente en el adelantamiento de procesos de esta índole, debe resolverse en favor del disciplinado.

El "in dubio pro disciplinado", al igual que el "in dubio pro reo" emana de la presunción de inocencia, pues ésta implica un juicio en lo que atañe a las pruebas y la obligación de dar un tratamiento especial al procesado.

Como es de todos sabido, el juez al realizar la valoración de la prueba, lo que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la Administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación en la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la Administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso; dependiendo de quien adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado." (Subrayado fuera de texto)

Conforme a lo anterior, se observa la imperiosa necesidad de garantizar al interior del proceso disciplinario, los preceptos del artículo 29 Constitucional que contemplan para el encartado su derecho al debido proceso; encontrándose en situ el de la presunción de inocencia y el de in dubio pro disciplinado; Lo anterior en concordancia por lo establecido por el artículo 20 de la ley 734 de 2002 que dispone como fines de la actuación disciplinaria la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas que en ella intervienen, así como del artículo 142 Ibídem que proscribe el proferimiento de fallo sancionatorio sin que obre prueba que conduzca a la certeza absoluta de la responsabilidad del disciplinado.

En tal sentido, después de analizar la probatoria obrante al interior de la presente actuación, se observa por parte de esta Subdirección la presencia de pruebas encontradas que inexorablemente generan dudas insuperables respecto de la ocurrencia del hecho. En tal sentido puede establecerse que se encuentran elementos suficientes para resolver la presente actuación a favor del señor XXXXX, en virtud del principio de In dubio pro disciplinado, teniendo en cuenta que, del material probatorio recolectado, se hace imposible superar las dudas sobre la ocurrencia del hecho.

6.3. DE LA CONTESTACIÓN A LOS ARGUMENTOS DEL INVESTIGADO

El abogado de la defensa solicita la absolución de su cliente basado en ciertas argumentaciones y premisas que en efecto a la postre están llamadas a prosperar, sin embargo, como se anticipó en el análisis probatorio hecho, se dará aplicación a la premisa constitucional de la duda a favor del procesado, pues dichas alegaciones, aunque ciertas no resultan suficientes para predicar la inocencia absoluta del implicado XXXXX

Entendida la duda como la "Suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia"², se entenderá que aún este punto procesal la duda subsiste, y subsiste por que el disciplinado dentro de sus argumentaciones defensivas no pudo explicar de manera convincente cuáles eran sus motivaciones para remitir a la dirección de correo electrónico XXXXX sus datos personales como cédula o número de cuenta de ahorros.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2013-205

Cabe recordar como se argumentó en escrito de cargos, que de manera inequívoca los correos estaban dirigidos a esta persona pues al dárseles lectura no hay forma de que exista si quiera un indicio que permita inferir que se trató de un descuido del señor XXXXX, esto adicionado al lenguaje y a las conversaciones que manejaron a lo largo de la expedición del trámite, que son indicios que no permiten deslegitimar o despejar las vacilaciones que existen sobre la total inocencia del funcionario.

En dicho proveído se manifestó lo siguiente:

"(...) Repara el despacho en que parte de las argumentaciones defensivas del funcionario redundan en aseverar que dicho correo pudo haber sido remitido por error, sin embargo, en su encabezado se lee "Osca Pérez", lo que significa que la misma iba dirigida inequívocamente al abogado (...)"

Por otro lado, si bien comparte y recibe este despacho las aseveraciones de las testimoniales respecto de que el trámite siguió un curso natural, que no permite evidenciar demoras o dilaciones intencionales, así como que el señor XXXXX el día 30 de mayo de 2013 se encontraba en un almuerzo con sus compañeros XXXXX Y XXXXX, no deslegitiman el hecho de que se surtió una llamada y un posible encuentro entre ambos sujetos en horas anteriores al almuerzo del cual no se tiene con certeza a qué hora inició, o las razones por las que el señor XXXXX se encontraba en Bogotá muy cerca del punto donde se encontraba el procesado, pero que a la postre constituyen pruebas indiciarias que a esta instancia no le permiten al despacho fallar en otro sentido.

En mérito de lo expuesto el suscrito,

RESUELVE

PRIMERO: ABSOLVER al señor XXXXX identificado con cédula de ciudadanía XXXXX, en su condición de Analista I de la Coordinación de Sustanciación de la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, respecto del cargo imputado en decisión no. 17406-00019 del 22 de agosto de 2016 acorde con las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002, a los sujetos procesales.

TERCERO: COMUNICAR la presente decisión en los términos del artículo 109 de la ley 734 de 2002 a la dirección electrónica XXXXX Real Academia de la Lengua Española/ <http://dle.rae.es/?id=EER7LDR>

CUARTO: ADVERTIR que contra la presente decisión procede el **RECURSO DE APELACIÓN**, conforme lo establecido en el artículo 115 Ibídem.

QUINTO: En firme la presente decisión, COMUNICARLA en la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 174 del Código Disciplinario Único.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE,

Jorge A. Moreno Ponce

JORGE ADRIANO MORENO PONCE
Subdirector de Investigaciones Disciplinarias
UAE Agencia ITRC